

1509272-18.2019.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... para a condenação dos réus pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

A negativa do acusado Rainer não encontra respaldo em qualquer elemento de prova, não sendo crível sua versão de que foi liberado inicialmente e, somente depois, soube da acusação de tráfico de cocaína. Também não se sustenta a versão de que não trocou mensagens com a ré Kauane por celular.

0 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1509272-18.2019.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509272-18.2019.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAINER CLEINER PADOVAN CEDRAN e outro

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

RAINER CLEINER PADOVAN CEDRAN e KAUANE JESUS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, porque: (i) no dia 17 de julho de 2019, por volta das 03h30min, na Rua Afonso Pena, n. 153, nesta cidade e Comarca, os denunciados traziam consigo, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 480g (quatrocentos e oitenta gramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo de fls. 15/17; (ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e local supra, os denunciados associaram-se para fins de praticar qualquer dos crimes previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas).

Os réus foram notificados (fl. 263 e fl. 270) e ofertaram defesa prévia (fls. 274/275). A denúncia foi recebida em 15/12/2021 (fls. 277/279) e o réu foi citado

(fl. 315). Em audiência de instrução e julgamento virtual, realizada em 8/6/2022 (fls. 3201/321 e mídia audiovisual), foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum e os acusados foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da denúncia, condenando os réus apenas em relação ao delito de tráfico de drogas. Na fixação da pena, deve ser considerada na primeira fase da dosimetria a grande quantidade e natureza da droga, bem como, em relação ao réu Rainer, os maus antecedentes. Na segunda fase há de ser valorar a confissão da ré Kauane. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena. Inviável a redução de pena do tráfico privilegiado, diante dos maus antecedentes do réu Rainer, bem como pelo fato da ré Kaune já ter sido processada por fato idêntico ao dos autos. Pelos mesmos motivos, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, sendo inviável a conversão em penas restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena. Por fim, requer o perdimento do numerário apreendido e dos aparelhos de telefone celular (conf. mídia audiovisual).

A Defensoria Pública, na defesa do réu Rainer, argumentou que a conduta a ele imputada é atípica, vez que o entorpecente não foi efetivamente entregue e não houve uma individualização específica de sua conduta na denúncia. Sustentou que a conduta que lhe é atribuída não se encaixa em nenhum dos núcleos incriminadores do artigo 33 da Lei 11.343/06, pleiteando a absolvição nos termos do artigo 386, incisos III ou VII do Código de Processo Penal. No tocante à associação, não se revela o ânimo associativo, sendo de rigor a absolvição nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, todavia, requer-se a aplicação da pena em seu patamar mínimo e a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, observando-se, se o caso, o disposto no artigo 382, §2º, do Código de Processo Penal.

Em favor da acusada Kauane foram ofertadas alegações finais e requerido, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal sem fundadas suspeitas. Além disso, a Defesa sustentou a inadmissibilidade das provas ilícitas ante a violação ao direito do silêncio. Por fim, requereu a absolvição por falta de provas em relação ao tráfico e a atipicidade em relação ao crime de associação porque não houve a unidade estável e permanente, de caráter duradouro. Em relação à pena, pleiteou a fixação da pena base no patamar mínimo, desconsiderando-se os maus antecedentes e incidindo a reincidência, a fim de evitar o "bis in idem", além da compensação com a atenuante da confissão. Acerca do regime, de rigor o mais abrandado, aplicando-se, se o caso, o disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Preliminarmente, afasto os argumentos defensivos de que a prova obtida é ilícita.

De início, rejeito a preliminar arguida pela Defensoria Pública de que os policiais deliberaram pela abordagem e revista pessoal sem nenhuma suspeita de prática criminosa ou qualquer situação de flagrância. Como apurado, os policiais realizavam patrulhamento de rotina, por volta das 3h00 horas da manhã, quando avistaram o casal em frente à residência e o réu Rainer se afastou em seguida, assim que notou a presença policial, rumando em direção ao portão da casa, o que ensejou a abordagem.

Ao fim, a abordagem de ambos resultou positiva para a apreensão de entorpecente e não decorreu diretamente da confissão informal dos autuados, mas da atitude suspeita considerando o horário dos fatos e a tentativa de um deles de se esquivar da ação policial, motivo pelo qual considero idônea a prova obtida. A par disso,

eventual irregularidade na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar o processo, especialmente se as provas são ratificadas em Juízo, como a análise do mérito apontará. A título de exemplo, destaco:

Apelação Criminal nº 1500355-85.2020.8.26.0631 -Voto nº 18034 5 "Bananeiras". Assim, os policiais civis iniciaram investigação e monitoraram o réu por bastante tempo; na data da prisão ficaram em campanha observando à longa distância e viram Luiz Miguel iniciar movimentação para ir em direção aos pontos do tráfico, por um pasto que ficava nos fundos da residência do réu. Conseguiram abordá-lo e consigo foi localizada quantidade significativa de drogas, além de dinheiro, um telefone celular e munição (cf. prova oral disponível via eSAJ e analisada a seguir). A título de exemplo: (...) 2. Inexistem direitos absolutos e ilimitados e, para que aparentes contradições entre princípios de igual matiz sejam solvidas - aplicando-se a norma constitucional de forma segura e coerente -, utiliza-se o princípio também constitucional da proporcionalidade. (...) 4. Em razão do alto grau de afetação de direitos e por ser vexatória e invasiva, a medida de busca pessoal é excepcional, devendo a autoridade policial agir com extrema cautela, evitando-se atos abusivos, somente levando-a a cabo quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, com objetos que constituam corpo de delito, com instrumento de crimes, entre outros. Não se pode dizer que os réus foram aleatoriamente escolhidos para a revista, sendo o procedimento adequado. (...) 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ HC nº 257.002/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, J. 17.12.2013, DJe 19.12.2013 g.n

A par disso, uma vez que foi localizada porção expressiva de entorpecente com um dos flagrados, faz parte da atuação policial que se questione a origem para apuração inicial dos fatos e até mesmo para não configurar constrangimento ilegal de inocentes ou meros usuários.

Ainda, aduz a Defesa em favor do réu Rainer, a inépcia da denúncia, eis que sua conduta não foi descrita de forma precisa e individualizada. Aponta que a droga não lhe foi entregue e que não há descrição de conduta que indique seu envolvimento com o tráfico, já que não foi surpreendido na posse, transportando drogas ou em qualquer outra ação inerente ao tipo penal.

O fato é que a abordagem foi legítima e a apreensão de entorpecentes com a corré Kauane não afasta a responsabilidade do acusado Rainer, pois ambos foram surpreendidos no momento da entrega da droga, havendo descrição fática suficiente ao exercício da ampla defesa, tanto que não se vislumbra a ocorrência de prejuízo neste aspecto.

Além disso, com a análise do mérito, restará comprovado que o réu manteve contato telefônico e aguardava a droga trazida pela ré, restando, portanto, sua conduta em consonância com àquela narrada na exordial acusatória.

No mais, a existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelas provas colhidas durante a instrução, tais como o boletim de ocorrência de fls. 7/9, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, cópia de passagem (fl. 13), pelos laudos de constatação provisória de fls. 15/17 e laudo químico toxicológico de fls. 18/20, este atestando a natureza da substância apreendida (cocaina), relatório de investigação e relatório de investigação complementar acerca do aparelho de telefonia móvel apreendido (fls. 194/202 e fls. 210/211), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 212/215) e prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Roberto Sudário e Maurício Fagundes de Oliveira, policiais

militares, declaram que estavam em policiamento quando avistaram o réu Rainer, já conhecido dos meios policiais, conversando com a ré Kauane. Ao avistar a viatura policial, o réu Rainer se afastou e tentou entrar na sua residência. Diante da atitude suspeita, realizaram a revista pessoal em ambos e com a ré Kauane encontraram um celular e duas porções grandes de cocaína. Com o réu Rainer encontraram apenas um aparelho de telefonia celular. Indagados, a ré Kauane confessou ter sido contratada, por R\$ 500,00, para trazer a droga de São Paulo/SP até Marília/SP. O réu Rainer também teria confirmado ter adquirido o entorpecente.

A testemunha Samantha Rossato Tomé Ruano, policial civil, declarou ter elaborado o laudo sobre os dados extraídos do celular do réu Rainer, tendo em vista que não foi possível extrair nenhuma informação do celular da ré Kauane. Embora não se recorde muito do conteúdo das conversas, havia mensagens em que alguém dizia estar chegando na cidade e perguntando para onde deveria ir.

O réu Rainer Cleiner Padovan Cedran, interrogado, declarou que é usuário de drogas há muito tempo, razão pela qual e que é bastante conhecido pelos policiais. No dia dos fatos foi abordado após ter comprado 20 “pinos” de cocaína na Vila Barros. Foi conduzido até a Delegacia e liberado em seguida. Disse que, posteriormente, soube estar sendo acusado de tráfico de grande quantidade de cocaína. Nega ter adquirido a droga, conhecer a ré Kauane e ter se comunicado com ela por celular.

A ré Kauane Jesus Dos Santos, interrogada, confessou ter praticado o delito, confirmando ter sido contratada, por R\$500,00, para entregar o entorpecente para o réu Rainer em Marília/SP. Durante o trajeto de ônibus até a cidade, trocou mensagens com o réu Rainer, para saber aonde deveria ir. Ingressou em um taxi, mas foi abordada pelos policiais militares antes de chegar na casa do réu Rainer.

Em que pesem os argumentos defensivos, há prova suficiente para a condenação dos réus pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

A negativa do acusado Rainer não encontra respaldo em qualquer elemento de prova, não sendo crível sua versão de que foi liberado inicialmente e, somente depois, soube da acusação de tráfico de cocaína. Também não se sustenta a versão de que não trocou mensagens com a ré Kauane por celular.

O relatório de fls. 194/202 esclarece que no celular apreendido com o réu havia uma mensagem no qual o interlocutor o chama pelo nome: “Rainer, o nike pediu pra vc me manda uma conta da caixa pra te transferi o dinheiro”. – fl. 196 e 200, permitindo, portanto, sua identificação.

E, na mesma análise, foram encontradas mensagens por ele enviadas a um celular cujo código de área é (11), ou seja, o destinatário era da Capital. Além disso, em uma das mensagens fornece seu endereço residencial e esse destinatário (fl. 198):

To: 011 98867-6602
Boa noite senhora
Rua Afonso pena n: 153
Prolongame

To: 011 98867-6602
Uma boa viagem pra senhora e que deus acompanhe

O endereço constante na mensagem pertence ao acusado (conf. fl. 62 e fl. 314/315). Nota-se, ainda, que as mensagens foram enviadas na data de embarque da correio Kauane, conforme passagem rodoviária copiada à fl. 13, e o destino dela era a cidade de Marília.

A troca de mensagem se encerra na madrugada do dia 17/9, sendo a última delas

encaminhada às 02:37:32 a partir do celular de código de área da Capital, com o seguinte texto: "Oiie, então acho a daki mais ou menos uma hora eu já chego" - fl. 195.

Não é coincidência, portanto, que a abordagem dos acusados tenha ocorrido justamente às 3h30min. da madrugada.

Os registros, ainda que breves, reforçam a troca de mensagens havida entre os réus, restando a versão do réu Rainer isolada nos autos.

A par disso, é evidente que as declarações da ré Kauane em Juízo estão em consonância com os relatos dos policiais militares acerca do trajeto por ela percorrido e do valor recebido para entregar o entorpecente ao corréu Rainer. Além disso, são sustentadas pela prova documental que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Cumprе destacar somente que a versão da acusada de que foi abordada no táxi, antes mesmo de se encontrar com o réu Rainer não merece guarida.

Em contrapartida, os relatos dos policiais militares foram coesos e uníssomos no sentido de que avistaram ambos os réus em frente à residência e, justamente, pela locomoção empreendida pelo acusado Rainer na tentativa de evitar a ação policial é que houve a abordagem.

Mais ainda, a narrativa dos policiais está respaldada pelas mensagens trocadas pelos réus durante o trajeto de São Paulo a Marília e pela passagem rodoviária constante nos autos, tornando temerária a versão de que não se encontraram na data dos fatos.

E não há motivo nos autos para negar crédito ao depoimento dos policiais responsáveis pela diligência. Primeiro, porque a valoração do relato dos agentes públicos deve ser feita pelo Estado juiz como qualquer outra prova testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre convencimento motivado (CPP, art. 155, caput). Segundo, porque os depoimentos de policiais compõem naturalmente o contexto probatório e inexistem indícios de que tenham interesse de causar gratuito e falso prejuízo aos acusados.

A quantidade de entorpecentes localizada na posse dos réus é expressiva e a forma como embalada não denota a posse para consumo, mas posterior fracionamento e venda para terceiros.

Apesar de não narrarem situação de comercialização, as condutas periféricas como trazer consigo, guardar, transportar ou mesmo manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do tipo penal. Neste sentido, é o entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06, assim, considera-se típica não apenas a venda, mas também o depósito e a guarda dos entorpecentes, hipótese dos autos." (STJ, Quinta Turma, HC 210.746/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 26/06/2012, DJe de 01/08/2012).

Portanto, a partir da suspeita, a diligência resultou positiva e a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico.

Nos termos do disposto no artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, existe a convergência de algumas situações indicativas do tráfico de entorpecentes, tais como: a) a tentativa do acusado de se esquivar da abordagem, em plena madrugada, tão logo

avistou a viatura policial; b) a apreensão de entorpecente em quantidade expressiva, trazida pela acusada da cidade de São Paulo e cuja entrega se destinava ao corréu Rainer, que certamente providenciaria o fracionamento em porções menores.

Como se vê, a prova oral está em consonância com a prova pericial que instrui os autos, inexistindo qualquer discrepância acerca da dinâmica dos fatos e revelando, sem qualquer dúvida, a ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, bem como a autoria do crime.

Tratando-se, especificamente, do delito de associação para o tráfico, com razão a Defensoria Pública. Não se revela entre os acusados um vínculo associativo, com unidade de propósitos, de forma habitual e permanente, nada havendo a respeito de hierarquia ou divisão de tarefas bem definidas entre eles e, por esta razão, a absolvição dos réus é medida que se impõe.

Nesse sentido o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

"Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006." (STJ - AgRg no HC 539.907/RJ T5 - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. em 17.12.2019 DJe em 19.12.2019).

Portanto, denota-se pelas provas coligidas que houve a completa subsunção da conduta dos réus ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Comprovadas a materialidade e autoria do delito, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em relação ao réu Rainer Cleiner Padovan Cedran, considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porque, apesar da quantidade do entorpecente, o réu é primário (fls. 258/261). A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, como mencionado, apesar dos diversos registros, são estes pautados em absolvições ou feitos nos quais o réu beneficiou-se do artigo 76 da lei 9.099/2005 e no processo 1501778-05.2019.8.2.60344 – fl. 261 – houve extinção com base nos artigos 107, IV c/c 111, I, do Código Penal (antes de transitar em julgado a sentença), não configurando Maus Antecedentes. Por fim, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Já em relação à ré Kauane Jesus Dos Santos, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, posto que não há registros que lhes sejam desfavoráveis, conforme certidões de fls. 256/257. No mais, a culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação à ré Kauane Jesus Dos Santos. Contudo,

não tem esta o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, ausente causas de aumento. Em que pese os réus serem tecnicamente primários (fls. 256/257 e fls. 258/261), deve ser levado em consideração o fato de que foram flagrados com quantidade expressiva de cocaína (504,59 gramas – fls. 10/11), droga de alto poder lesivo, além do que permitiria fracionamento em quantidade ainda maior, motivo pelo qual deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo a reprimenda permanecer como dosada na primeira fase.

Desta forma, torno definitiva a pena dos acusados Rainer Cleiner Padovan Cedran e Kauane Jesus Dos Santos em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelas condições econômicas dos réus, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR os réus Rainer Cleiner Padovan Cedran e Kauane Jesus Dos Santos, devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para ABSOLVÊ-LOS da imputação descrita no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pena privativa de liberdade de ambos os réus deve ser cumprida em regime inicial fechado. Tratando-se de crime equiparado a hediondo, que causa consequências gravíssimas à sociedade, alimentando o crime organizado e destruindo as famílias dos dependentes químicos, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, a fim de que sejam atingidos os objetivos de prevenção geral e específica da punição criminal, especialmente pela expressiva quantidade de droga apreendida.

Anoto que, diante da pena fixada é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

Ante a ausência de elementos concretos a embasar a necessidade da prisão preventiva, concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Em face da condenação supra, os sentenciados arcarão com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, decreto o perdimento do bem, consistente em: 1 telefone celular, marca Samsung e 1 telefone celular, marca Motorola, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, bem como a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, oficiando-se, após o trânsito em julgado.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA